

1500533-50.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500533-50.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500533-50.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093692/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 24104137 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, AX5170-1/2022 - Delegacia de Polícia de Birigui, 2093692 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON WILLIAM CARDOSO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500533-50.2022.8.26.0603 (Controle nº 792/2022).

VISTOS.

ANDERSON WILLIAM CARDOSO SILVA, alcunha "Facada", menor de 21 anos, qualificado nos

autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 19h, à Rua Justino Fernando Calhari, nº 682, nesta cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 52,63 (cinquenta e dois gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína, fracionadas em 60 (sessenta) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 03 (três) cartões bancários, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação prévia (fls. 15), laudo de exame toxicológico (fls. 62/64).

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas acima, ANDERSON WILLIAM CARDOSO SILVA, alcunha "Facada", possuía, nas dependências de sua residência, 16 (dezesesseis) munições íntegras, de calibre nominal .380, das marcas FLB e CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 65/69.

Recebida a denúncia em 28 de abril de 2022 (fls. 84/85), o acusado foi regularmente citado (fls. 97) e apresentou defesa escrita às fls. 104/105.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 130/131).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 141/147).

Por outro lado, a defesa requereu a absolvição do réu, alegando ausência de provas.

Subsidiariamente, requereu desclassificação do crime de tráfico para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu aplicação da pena no mínimo legal; a aplicação do parágrafo 4º do art. 33 da lei de drogas; o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade penal relativa; a fixação do regime aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; o direito de o acusado recorrer em liberdade; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo, ante a simples situação econômica do acusado (fls. 150/160).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, da Lei nº. 10.826/03).

No mérito, a ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; a nota de culpa de fl. 11; o boletim de ocorrência acostado às fls. 03/07; o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 12/13; o laudo de constatação prévia de fl. 15; depósito judicial de fl. 60; os laudos periciais de fls. 62/64 e 65/69; o relatório policial de fls. 75/76; os depoimentos das testemunhas; e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na fase policial, o acusado negou a prática dos delitos. Relatou que estava a caminho da casa de sua namorada, quando foi abordado pelos policiais militares, próximo do imóvel em que foram encontrados os cartões, drogas, celular, carteira e munições de arma de fogo, os quais não lhe pertenciam. Disse que estava apenas com um celular azul e R\$ 20,00, e apesar de constar seu nome completo nos cartões encontrados no interior do imóvel, eles não lhe pertenciam (fl. 10).

Em Juízo, o acusado continuou a negar a prática dos delitos, no entanto, apresentou contradições. Disse que não estava traficando e que é usuário de drogas, motivo pelo qual teria ido buscar seus cartões que deixou "penhorado" com o traficante. Afirmou que deixou seus documentos em troca das drogas. Tinha conhecimento que havia droga no local, mas que não sabia das munições de arma de fogo. Estava no

imóvel esperando o traficante retornar pois havia saído para guardar um dinheiro. Disse que os policiais o viram junto do traficante em frente ao imóvel, porém o traficante empreendeu fuga e não foi abordado. Disse que, no momento da abordagem, não estava com nenhuma droga, apenas com o celular e R\$ 20,00 (vinte reais) no bolso. As drogas e munições foram encontradas dentro do imóvel. Afirmou que estava cuidando da "biqueira" até o traficante retornar. Por fim, disse que não tem apelido (fls. 130/131).

Como se vê, o réu apresentou contradições em seus interrogatórios. Na delegacia, disse que não estava no imóvel, pois estava a caminho da casa de sua namorada, e que os cartões com seu nome não lhe pertenciam. Já em juízo, disse que os cartões eram seus e que estavam como garantia em troca de drogas; que estava na residência cuidando do ponto de venda de drogas, enquanto o traficante estava ausente; e que os policiais o viram com outra pessoa na frente do imóvel.

Diante dessas contradições, relacionadas a ponto de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelo acusado, que estão totalmente contrárias às provas coligidas nos autos e isoladas de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariadas por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por condutas efetivamente praticadas.

Com efeito, as testemunhas Alécio Gaiarin, e Alekssander Xavier Conrado, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo de motocicleta em frente ao imóvel, onde possuía diversas denúncias de que o acusado, vulgo "Facada", estaria traficando. O acusado saiu do imóvel em direção ao motociclista, momento em que percebeu a presença dos policiais e se evadiu do local em alta velocidade, não sendo abordado. Abordado o acusado, foram localizados com ele 05 (cinco) microtubos contendo cocaína e R\$20,00 (vinte reais). Questionado, o réu informou que estava sozinho, indicou onde havia mais drogas e munições de arma de fogo no interior do imóvel. Foram encontrados mais 55 (cinquenta e cinco) microtubos contendo cocaína, 16 (dezesesseis) munições intactas de calibre .380, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), três cartões bancários com o nome do acusado e dois celulares. O acusado disse que invadiu o local para vender drogas e que o dinheiro encontrado era proveniente do tráfico. O acusado disse que as munições eram suas, referente a uma arma que já havia vendido. A carteira do réu estava no mesmo local onde foram encontradas as drogas. (fls. 08, 09 e 130/131).

Como se vê, os policiais militares confirmaram que o réu confessou a posse das munições de arma de fogo e a prática da traficância, o que põe por terra a alegação do acusado de que havia deixado seus cartões e documentos com o traficante como garantia da compra de drogas.

Anoto que o valor do depoimento de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando seus depoimentos não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de condutas definidas como crimes, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Ainda quanto aos policiais militares, é cediço que o valor de seus depoimentos testemunhais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Note-se, ainda, que o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, logo, estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há motivo para desprezá-los, apenas por se tratar de policiais.

Quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se, ainda:

“Tóxicos – Tráfico – Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação, ou tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Procedente” (STF – 2a T. – HC n.º 74.522-9/AC – Rel. Min. Maurício Corrêa – DJU 13/12/96, pág. 50.167).”

“Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1a Turma – HC n.º 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Por tudo que foi exposto quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há o que se questionar quanto as suas declarações.

Quanto as munições, o laudo pericial de fls. 65/69 apurou que os cartuchos estavam aptos para realizar disparos.

No que se refere aos entorpecentes apreendidos, a perícia apontou que consistem realmente em “cocaína” (exame químico-toxicológico de fls. 62/64).

De outra parte, o entorpecente apreendido, ou seja, 52,63 (cinquenta e dois gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína; as circunstâncias da abordagem do réu (denúncias de que o réu estaria traficando naquele local), a forma de acondicionamento da droga (distribuídas em porções prontas para o comércio); apreensão de celulares e dinheiro; e a confissão do réu aos policiais militares, estão a caracterizar a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado porque trazia consigo e guardava os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

O simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Lembre-se de que o réu, em juízo, afirmou que estava cuidando do ponto de drogas (“biqueira”) para o traficante, o que só vem confirmar a prática do tráfico de drogas, cuja prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria dos crimes por parte do réu, nos crimes ora apurados.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão

inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo e guardava 52,63 (cinquenta e duas gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, e possuía, 16 (dezesesseis) munições de calibre .380 intactas, de uso permitido, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As condutas do réu encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e 12, caput, da Lei 10.826/03. Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, não há que se falar em desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que o acusado sequer assumiu que o entorpecente apreendido lhe pertencesse. do crime para o do artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que o acusado sequer assumiu que a droga fosse dele, limitando-se a

Assim, irrelevante o fato de o réu ser ou não usuário, porque não assumiu a propriedade da droga, não havendo sequer espaço para se falar em desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio.

Por outro lado, ainda que se admitisse o acusado como usuário e ainda que ele tivesse assumido que a droga lhe pertencesse, esse fato, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas: se o réu é usuário há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de droga não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

De uma forma ou de outra, portanto, não há que se falar em desclassificação do crime imputado para o de uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06. Reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas separadamente.

Das penas.

Posse ilegal de munição de uso permitido.

Ao que consta dos autos, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, razão pela qual as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis. Fixo, assim, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa, mas deixo de reduzir a pena, pois já estabelecida em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ). No mais, não há outras atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Torno, pois, definitiva a pena em 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Tráfico de drogas.

O acusado não ostenta maus antecedentes e as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa, mas deixo de reduzir a pena, pois já estabelecida em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento de pena, no entanto, estão preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, haja vista que o réu é primário, não consta possuir maus antecedentes, além do que não há provas dando conta de que o réu se dedique a atividades criminosas ou

integre organização criminosa. Portanto, reduzo as penas em 1/2 (metade), resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Observo que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material, com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Quanto ao tráfico de drogas, diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Neste ponto, anoto que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ª Turma do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi cassada pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, no julgamento do RE nº 1.344.374, em 01/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Quanto ao crime de posse de munição, em razão da quantidade da pena ora fixada, poderá o réu cumpri-la em regime aberto.

Quanto ao crime de posse de munição, em razão da quantidade da pena ora fixada, poderá o réu cumpri-la em regime aberto.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Neste ponto, anoto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que inexistente previsão legal para a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa.

Ademais, cabe consignar que a pena de multa é uma modalidade de reprimenda cominada à infração penal, sendo vedada a sua exclusão, sob pena de o pedido de isenção formulado pelo sentenciado se transmutar em supedâneo recursal, o que, em hipótese alguma, se pode admitir.

Descabida, portanto, a pretensão da defesa técnica quanto ao não pagamento da multa imposta ao réu.

Quanto ao pedido relativo à dispensa das custas processuais, o mesmo não comporta acolhimento, pelos mesmos motivos já expostos acima, lembrando que, recentemente, o Tribunal de Justiça editou ato normativo aos juízes, para que se empenhem na cobrança das custas processuais devidas em processos criminais, nos termos do que determinam as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

1) CONDENAR ANDERSON WILIAM CARDOSO SILVA ao cumprimento pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-o como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Apesar de preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal (pena não superior a quatro anos e réu não reincidente em crimes dolosos), entendo que o requisito do inciso III do mesmo artigo não se mostra presente, porque, além

das munições, também mantinha sob sua guarda cocaína, para fins de tráfico de drogas, indicando que, no caso em especial, a substituição do artigo 44 do Código Penal não é suficiente para a repressão e prevenção do delito, vez que admitir um traficante, que possuía munição de arma de fogo, prestar serviços em escolas e outras entidades públicas, colocaria em risco as pessoas que delas se utilizam, inclusive crianças inocentes, o que, de forma alguma, se pode admitir.

2) CONDENAR ANDERSON WILIAM CARDOSO SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 06/04/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Quanto a este crime (tráfico), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 0094294-30.2012.8.26.0000, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênica, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara).

Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante

encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).



O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 37/39), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga apreendida já foi determinada e realizada (fls. 125/129 e 132), razão pela qual nada há a ser decidido a respeito.

Restou provada a procedência ilícita do dinheiro apreendido (fls. 12/13 - R\$ 170,00), razão pela qual não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente praticado pelo acusado. Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido e depositado nos autos à fl. 60.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supra determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos cartões e pote plástico de cor azul com tampa vermelha, diante da natureza dos objetos, entendo não ser caso de perda, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos, independentemente do trânsito em julgado da presente.

Em relação aos celulares apreendidos às fls. 12/13, diante da natureza dos objetos, (e por serem, os celulares, instrumentos para a prática do tráfico de drogas), entendo não ser caso de perda para o SENAD, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, mas que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado da presente.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos objetos e perdimento do dinheiro apreendido, instruindo-se o ofício com as cópias. No tocante às munições apreendidas (fls. 12/13), já foi elaborado o laudo pericial e as partes dele já tomaram ciência. Não há notícia de que a munição pertença a terceiro de boa-fé, para fins de notificação quanto ao interesse em sua restituição, além do que a guarda da munição não é imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados no processo (art. 1º, § 1º, Res. 134/11 do CNJ). Portanto, com fundamento no artigo 1º, caput, da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça, c.c. o artigo 3º do Provimento nº 1924/11 do Conselho Superior da Magistratura, determino o encaminhado da munição ao Comando do Exército, para destruição, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03, independentemente do trânsito em julgado.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA